

1500664-35.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/05/2022

... (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, caput, Lei de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500664-35.2021.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500664-35.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2062969/2021 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 16594769 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 28/21/819 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 2062969 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON RICARDO MANOEL e outro

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

WESLEY BALMANT DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e ANDERSON RICARDO MANOEL, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 331 do Código Penal, na forma do artigo 69, do mesmo código.

Consta do incluso inquérito policial, lavrado em decorrência do auto de prisão em flagrante que, na data de 04 de março de 2021, por volta das 15h30min, em via pública na Rua Guido Antônio, esquina com a Avenida Higino de Barros Camargo, Parque Hippolyto II, nesta cidade e comarca de Limeira/SP, os acusados adquiriram, venderam e tinham em depósito, para ser entregue a consumo de terceiros, em atividade de tráfico ilícito, 23 porções de cocaína, pesando 10,17g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias supramencionadas, o acusado ANDERSON desacatou policiais civis, funcionários públicos estaduais, que estavam no exercício de suas funções.

Segundo o apurado, os denunciados adquiriram e receberam considerável quantidade de cocaína para desenvolver o comércio ilícito de drogas no bairro Parque Hippolyto II e adjacências.

Na data dos fatos, policiais civis realizavam diligências com viatura descaracterizada na repressão ao tráfico ilícito de tóxicos. Na ocasião, WESLEY foi surpreendido no local dos fatos por investigadores de polícia, enquanto entregava porções de cocaína a um transeunte, do qual recebeu valores em troca.

Nesse momento, o denunciado ANDERSON, desconfiando tratar-se de viatura policial descaracterizada, abordou o veículo e bateu duas vezes no vidro do automóvel. Na oportunidade, afrontando os policiais civis Tiago e Ricardo, ameaçou-os dizendo que iria pegar o “trezoitão”. Ato contínuo, ele se distanciou da viatura.

Em seguida WESLEY abaixou-se ao lado da motocicleta “HONDA/CG 125 FAN KS”, placa EOG5207, que estava estacionada em via pública, e manuseou na lateral do motociclo, bem como no entulho que estava no solo. Logo, após, ANDERSON conversou com um motociclista e WESLEY lhe entregou drogas, recebendo valores em troca. As imagens foram captadas pela câmera de telefone móvel de um dos agentes públicos.

Seguidamente, os informes e a filmagem foram passados a outros integrantes da equipe policial, que se dirigiram até o local. O denunciado WESLEY empreendeu fuga, mas foi posteriormente abordado pelos agentes públicos.

Em continuidade à diligência, no local onde os denunciados estavam os investigadores de polícia encontram e apreenderam quatro porções de cocaína da tampa lateral da motocicleta de WESLEY, bem como dezenove porções da mesma substância e o valor de R\$60,00 no entulho, ao lado do motociclo.

Diante das condutas visualizadas e registradas em vídeo pelos policiais civis, os denunciados foram presos em flagrante delito.

Oferecida à denúncia, determinou-se a notificação dos réus para que apresentassem defesas preliminares, que vieram aos autos (fls. 169/177 e 204/205).

A denúncia foi recebida em 17 de dezembro de 2021 (fls. 206/208).

Durante a audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas e o réu WESLEY interrogado ao final. Foi decretada a revelia de ANDERSON (mídia).

Encerrada a instrução, as partes manifestaram-se.

Alegações finais escritas do Ministério Público (fls. 237/245) e memoriais orais da Defesa dos réus WESLEY e ANDERSON (mídia).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/06),

boletim de ocorrência (fls. 25/27), auto de exibição e apreensão (fls. 28/29), laudo pericial com resultado positivo para "cocaína" (fls. 35/36 e 180/182), gravações (fls. 75), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa.

Perante a Autoridade Policial, o acusado WESLEY confessou que vendia drogas no local da prisão (fls. 09/10).

Em Juízo, o acusado WESLEY disse que tem 30 anos. Está trabalhando registrado numa lanchonete. Contou que na época da prisão era usuário e não tem orgulho do que fazia. Fez tudo aquilo para manter o seu vício. Estava sem dinheiro e sem condições de comprar drogas. Estava no local para vender drogas e sustentar seu uso. ANDERSON sempre ficava ali na rua, usando drogas. Não tem qualquer vínculo com ele. Monica é uma mulher que fica na rua, é usuária de drogas. ANDERSON estava no dia da prisão. ANDERSON queria um pino para prestar auxílio, pediu para ele sair de perto, mas mesmo assim ANDERSON continuou por ali. ANDERSON fazia gestos apontando na sua direção. Não pediu nada a ANDERSON, ele fez por si mesmo. Não chegou a fazer muitas vendas. Hoje trabalha como garçom numa lanchonete e está registrado. Nunca mais fez uso de drogas. Está arrependido e nunca mais quer saber do tráfico de drogas. Confessa que estava traficando para seu uso e está muito arrependido, pois tem uma filha e precisa cuidar dela. Não quer mais essa vida. Essa motocicleta era da sua parente, ela não sabia que ele havia pego a coisa. Já tentaram várias internações, mas sempre fugia com medo de ser internado. Não sabe dizer se ANDERSON era olheiro de outras pessoas. Sempre via ele na rua, mas não tinha contato (mídia).

Perante a Autoridade policial, o acusado ANDERSON admitiu que participou do tráfico praticado por WESLEY (fls. 12/13).

Em Juízo, o acusado ANDERSON não foi interrogado por ser revel.

A prova oral confirma a confissão judicial e extrajudicial dos réus.

O policial Rafael Silva Varuzza disse que estavam divididos em duas equipes para coibir o tráfico de drogas naquela região. Dava suporte no apoio. O policial Tiago disse que filmou duas vendas de drogas de um rapaz de camiseta cinza (WESLEY), junto com um rapaz de pele negra (ANDERSON). Eles pediram ajuda na abordagem. ANDERSON tumultuou a ocorrência. No local WESLEY saiu correndo. Foram encontradas drogas. Os dois acusados foram conduzidos até o distrito policial. Havia um pouco de droga na motocicleta, que era de WESLEY, assim como drogas em outro local ao lado. Indagados, ambos negaram a prática do delito. ANDERSON era a pessoa de pele negra, o auxílio prestado era que ANDERSON dava sinais e setas em favor de WESLEY. Quem viu os sinais foram os policiais Tiago e Ricardo, que filmaram as vendas. Quem fez as vendas era WESLEY, ANDERSON auxiliava o comparsa. Foi ANDERSON quem tumultuou a ocorrência com desacatos. A indicação era que ANDERSON dava sinais e ajudava WESLEY na traficância. Não conhecia os dois acusados. Quem fugiu foi WESLEY. Parte das drogas foram encontradas na motocicleta de WESLEY. Também havia dinheiro ao lado. Quem localizou as drogas na motocicleta de WESLEY foi o policial Tiago; Também havia drogas no entulho. ANDERSON tinha cara de usuário, WESLEY aparentava estar esperto com a presença dos policiais (mídia).

O policial civil Anderson disse que os policiais Ricardo e Tiago estavam em viatura descaracterizada, o local é muito conhecido pela traficância. Eles já tinham filmado duas vendas. ANDERSON, um rapaz de cor, foi na viatura e passou a bater nos vidros proferindo várias ameaças. O rapaz de cinza era WESLEY. Foram até o local dar apoio na prisão. Abordou ANDERSON. WESLEY saiu correndo e o policial Rafael foi atrás dele, prendendo-o mais para frente. Nesse meio tempo Tiago foi no local onde as drogas eram escondidas. Foram localizados entorpecentes na motocicleta e no entulho. Indagados, eles negaram a prática do delito. Fazia parte da equipe de

apoio junto com o policial Rafael, estavam à distância. A motocicleta estava parada, WESLEY não estava no motociclo. O policial Tiago filmou WESLEY buscando drogas na motocicleta. Nunca havia abordado os acusados (mídia).

O policial civil Tiago Andrade Pucci disse que eles estavam em duas equipes. Ele e Ricardo iriam fazer as filmagens, ao passo que Anderson e Rafael ficaram em outra viatura mais distante dando apoio. Pararam a viatura descaracterizada na Rua Guido Antônio. Um réu (WESLEY) fazia a venda enquanto o outro (ANDERSON) ficava direcionando os usuários para fazerem a compra de WESLEY. ANDERSON ficava direcionando e olhava para ver se não tinha viatura policial. ANDERSON foi até a viatura descaracterizada e os xingou. Chamaram o apoio. Os policiais civis Rafael e Anderson chegaram, WESLEY saiu correndo. O policial Rafael prendeu o acusado que fugiu. Com ANDERSON não havia nada. Foi no local que WESLEY se aproximava na filmagem, encontraram pinos de cocaína, assim como dinheiro no entulho. Havia uma motocicleta. O motociclo era de WESLEY, não sabia que era dele até então. WESLEY ia próximo da motocicleta e mexia nela, assim como na calçada. Nesses locais encontraram as drogas. Viram o réu WESLEY agachado. Indagados, ambos negaram a prática do delito. ANDERSON falou que iria buscar uma arma para mata-los, ele bateu no vidro e proferiu muitos xingamentos contra eles. ANDERSON dizia que iria matar os policiais, isso ocorreu quando os policiais ainda estavam dentro da viatura descaracterizada. Fizeram a filmagem, foram duas vendas por parte de WESLEY. Acredita que só filmaram as vendas, mas ANDERSON dava sinais, foram cerca de três sinais. ANDERSON avisou WESLEY que poderia ter polícia na região. O corréu ANDERSON gritava para que as pessoas fossem em direção ao acusado WESLEY. Nas duas vendas que foram filmadas, ANDERSON havia dado sinal. A ocorrência durou cinquenta minutos, não foi muito demorado, desde o início até a finalização. O dinheiro estava no entulho, enquanto as drogas estavam na motocicleta e ao lado. Não viu ANDERSON negociando as drogas, ele dava auxílio a WESLEY. Não se recorda se ANDERSON estava sob efeito de drogas (mídia).

O polícia civil Ricardo disse que o local é um ponto de venda de drogas bem conhecido nos meios policiais. Pararam no local para filmar a ação, outra equipe deu apoio. Filmaram duas vendas. Um dos réus prestava auxílio, o outro vendia drogas. O acusado ANDERSON foi até a viatura e fez gestos de ameaça. O policial Rafael foi atrás de WESLEY, que fugiu. O policial Tiago encontrou drogas na motocicleta e dinheiro no entulho ali perto. Acredita que o acusado ANDERSON reconheceu a viatura policial descaracterizada. ANDERSON proferiu ameaças contra eles (mídia).

No que toca aos depoimentos de policiais civis, é de rigor consignar que aqueles não podem ser valorados de forma depreciativa, mormente se de acordo com os demais elementos do conjunto probatório.

Nesse sentido:

“(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, “a priori”, valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais “lato sensu”. Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j.

05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10). (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

A Defesa do corréu WESLEY arrolou testemunha.

A testemunha Daiane Pereira da Silva é irmã de WESLEY. Contou que seu irmão estava no local traficando para conseguir dinheiro. Ele era usuário de drogas e chegava a ficar uma semana fora de casa. O réu traficava para sustentar seu vício. A motocicleta era da parente de WESLEY. Ela não sabia que ele estava indo na biqueira com aquela motocicleta. Hoje WESLEY está trabalhando numa lanchonete e é casado, tem uma filha. Conhece de vista o acusado ANDERSON e sabe que fica na rua fazendo uso de drogas (mídia).

Pois bem.

Passo a analisar os delitos separadamente.

Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06

Pelo que se verifica da prova oral, policiais civis realizavam diligências com viatura descaracterizada, ocasião em que o acusado WESLEY foi surpreendido no local dos fatos pelos agentes públicos, no momento em que traficava, com duas vendas filmadas pelos agentes públicos.

Como o acusado ANDERSON desconfiou da viatura descaracterizada por atuar em conjunto com WESLEY na traficância ilícita, aquele réu abordou o veículo descaracterizado e bateu no vidro do automóvel, afrontando os policiais, chegando a dizer que iria pegar o "trezoitão", passando a desacata-los

Como os policiais civis resolveram aborda-los, o réu WESLEY tentou empreender fuga, mas foi abordado posteriormente. Em buscas pelo local dos fatos, os policiais civis encontraram e apreenderam quatro porções de cocaína, bem como dezenove porções da mesma substância e o valor de R\$ 60,00, no entulho, que estava ao lado do motociclo.

Os acusados foram presos em flagrante delito. Interrogados pela Autoridade Policial, ambos confirmaram a prática do tráfico.

Assim, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à autoria do crime de tráfico imputado envolvendo os acusados WESLEY e ANDERSON, haja vista a quantidade, a natureza e a forma como estavam embaladas as drogas (cocaína), as circunstâncias da prisão, o depoimento incriminador dos policiais civis e a confissão extrajudicial dos réus e a confissão judicial de WESLEY, tudo a apontá-los como sendo pessoas envolvidas no tráfico de drogas.

Sobre o tema em comento, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo é remansosa:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de drogas - Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 - Absolvição ou, ainda, desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas - Descabimento - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Palavra dos policiais militares - Credibilidade - Precedentes - Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas

circunstâncias fáticas da prisão – Ausência de visualização de atos de mercancia – Irrelevância – Tipo misto ou de conteúdo variado – Condenação mantida (...) ". (TJSP; Apelação 0004568-50.2015.8.26.0126; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/09/2017; Data de Registro: 11/10/2017).

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...) Materialidade e autoria delitiva comprovadas, sobretudo diante dos relatos seguros dos policiais militares que participaram da diligência. Escusa ofertada pelo réu isolada no quadro probatório. Impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Condenação mantida (...)". (TJSP; Apelação 0000137-25.2017.8.26.0571; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 01/03/2018).

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADA, EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO, INCONSISTENTE A NEGATIVA DE AUTORIA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, LOCAL DA ABORDAGEM, CONHECIDO PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES, MODO COMO OS ESTUPEFACIENTES ESTAVAM EMBALADOS, QUANTIDADE SIGNIFICATIVA E NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA COMPATÍVEIS COM O TRÁFICO(...) (TJSP; Apelação 0002975-45.2014.8.26.0344; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 9ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Marília - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/09/2017; Data de Registro: 26/09/2017).

Segundo entendimento do saudoso Luiz Flávio Gomes:

"Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (GOMES, Luiz Flávio e CUNHA. Rogério Sanches (Coordenadores). Legislação Criminal Especial. Volume 6. São Paulo: Editora RT, 2009).

Não há que se falar em desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, principalmente em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas, assim como as circunstâncias da prisão em flagrante, existindo depoimento incriminador de policiais civis envolvendo ambos os réus.

Na esteira dos ensinamentos de Cleber Masson:

"Os critérios mencionados devem ser aferidos conjuntamente. Apenas um deles, isoladamente, nem sempre conduzirá o intérprete a adotar a melhor solução. Perceba-se, por curial, que uma quantidade relativamente pequena de droga não indica, necessariamente, que o sujeito ativo a tem para consumo pessoal. Como se sabe, é cada dia mais incomum a existência de grandes depósitos de drogas. Os traficantes, justamente para dificultar a ação repressiva do Estado, têm preferido muitas vezes trabalhar com pequenas quantidades distribuídas entre várias "mulas " (MASSON, Cleber. Lei de Drogas: aspectos penais e processuais. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019).

Não é diferente o posicionamento jurisprudencial:

"Tráfico de entorpecentes – Dolo de traficar – Desclassificação para porte de entorpecentes (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – Descabimento Provado o dolo genérico de traficar, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não cabe a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, se for observado que as demais circunstâncias

que cercaram a prisão do acusado dão conta da caracterização do tráfico de entorpecentes (...)" (TJSP; Apelação 0002093-84.2015.8.26.0300; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jardinópolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 06/03/2018).

"APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Apreensão de porções de "maconha", "crack" e cocaína. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente pretende a desclassificação para consumo pessoal, o reconhecimento da figura privilegiada, o abrandamento do regime prisional, a substituição da carcerária por restritivas de direitos e a inconstitucionalidade da pena de multa. Materialidade e autoria indubitáveis. Réu preso em flagrante na posse de entorpecentes, na via pública, após delação anônima feita aos policiais. Quantidade e diversidade denotam a traficância..." (TJSP; Apelação 0005361-26.2016.8.26.0361; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

Não se exige a existência do efetivo comércio para a configuração do crime do artigo 33, "caput", da Lei de Drogas. Basta a guarda, o transporte, o trazer consigo, ou a manutenção em depósito, com a finalidade de distribuição ou de entrega a terceiros para que o crime se consuma.

A lei penal pune a mera finalidade (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, caput, Lei de Drogas).

Em se tratando de crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, de modo que é condenável a simples possibilidade de distribuição, gratuita ou onerosa, do entorpecente.

Em comentários ao artigo 33 da Lei de Drogas, o saudoso Luiz Flávio Gomes preleciona:

"(...) Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (p.ex., expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa (...)" (GOMES, Luiz Flávio et al. Nova Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo: Lei 11.343/06 de 23.08.2006. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006).

É esse o caso dos autos.

Não prospera a tese de desclassificação para o artigo 37 da Lei de Drogas (informante colaborador) suscitada pela Defensoria Pública. Apesar de alegar que ANDERSON apenas exerceu a função de "olheiro", as provas colhidas demonstram a ligação dele com o hediondo comércio, atuando ativamente no tráfico ilícito de drogas, participando diretamente da própria execução do crime (em divisão de tarefas com WESLEY), o que não se confunde com a conduta prevista no artigo 37 da Lei nº 11.343/06, de mero prestador de informações.

Como conclui Cleber Masson:

"Em verdade, nem toda espécie de colaboração é englobada pelo art. 37 da Lei de Drogas. De fato, a "colaboração material" normalmente acarreta em verdadeiro auxílio ao narcotráfico, fazendo com que o "colaborador" seja considerado partícipe

do tráfico de drogas. Além disso, também é possível cogitar da participação no tráfico de drogas pela "colaboração moral", quando então o sujeito será alcançado pela norma de extensão pessoal contida no art. 29, caput, do Código Penal, por ter instigado ou induzido o autor deste delito. Finalmente, a colaboração mediante financiamento ou custeio ao tráfico de drogas pode configurar o delito tipificado no art. 36 da Lei 11.343/2006" (MASSON, Cleber. Lei de Drogas: aspectos penais e processuais. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019).

Artigo 331 do Código Penal (desacato).

O crime de desacato envolvendo o acusado ANDERSON também restou configurado. Os policiais civis foram coerentes e precisos na descrição dos fatos, em todas as suas circunstâncias, de modo que suas informações ganham destaque.

Ao contrário do que foi exposto pela combativa Defesa, há diferença entre o direito constitucional de liberdade de expressão e ofender o agente público no exercício da função, menosprezando-o, como na hipótese em tela.

Em tais condições, não se pode deixar de acreditar na versão dos funcionários públicos, que se encontravam no exercício de suas funções, no sentido de que houve o desacato descrito na denúncia, não sendo caso de desclassificação para o delito de ameaça.

A esse respeito, confira-se:

"DESOBEDIÊNCIA e DESACATO - Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada - Condenação mantida. (...)" (TJSP; Apelação Criminal 0000708-13.2014.8.26.0470; Relator (a): Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Porangaba - Vara Única; Data do Julgamento: 20/01/2022; Data de Registro: 20/01/2022).

"Apelação criminal - Desacato e Resistência. Recurso defensivo dos réus que busca a absolvição ante a atipicidade de conduta, por legítima defesa e ausência de dolo. Aduziu que houve uma "reação à autuação arbitrária e desproporcional do policial militar". Autoria e Materialidade comprovadas (...) Crime de desacato - Autoria e materialidade que também restaram comprovadas - Acusados que efetivamente desacatarem funcionários públicos no exercício de suas funções, proferindo expressões de baixo calão. Delito de resistência igualmente comprovado - Policial que relatou que o acusado Victor resistiu à prisão, inclusive sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo - Decreto condenatório mantido.(...) Concurso Material de Crimes: crimes decorrentes de ações e desígnios autônomos, sem a existência de nexo de dependência ou subordinação entre eles, afastando-se a alegação de consunção. (...)" (TJSP; Apelação Criminal 1508124-28.2019.8.26.0002; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Regional II - Santo Amaro - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/01/2022; Data de Registro: 12/01/2022).

Não merece acolhimento a alegação de que a punição pelo delito de desacato não foi recepcionada pela Constituição Federal, além de não se mostrar compatível com a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, já que o delito de desacato está previsto regularmente na legislação penal, estando em pleno vigor.

Ademais, não há qualquer decisão de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, muito menos notícia de revogação por outra norma penal, havendo presunção de validade da norma penal, em conformidade com o julgado abaixo:

"(...) Da mesma forma, não há que se falar em inconstitucionalidade ou incompatibilidade do crime de desacato com Tratados e Convenções Internacionais, na

medida em que a garantia constitucional de liberdade de expressão não se trata de direito individual de caráter absoluto, porquanto o exercício de um direito está limitado pelo direito de outrem, in casu, pelo prestígio da Administração Pública e pela honra do funcionário público, no exercício de sua função (...)” (TJSP; Apelação 0004919-98.2014.8.26.0565; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Caetano do Sul - 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 19/04/2018; Data de Registro: 24/04/2018).

A tese defensiva de que a violenta emoção descaracterizaria o dolo específico não merece ser acolhida. É que o crime de desacato não deixa de existir porque o autor da ofensa estava alterado no momento em que proferira a ofensa, se não há outros elementos que possam tornar inexigível conduta diversa.

Com efeito, o desacato é crime de mera conduta que se perfectibiliza no momento em que são proferidas as palavras, as ameaças, ou os gestos, que têm por objeto desprestigiar, espezinhar, humilhar o servidor público no exercício de suas funções, visando com isto, atingir o Estado.

O tipo legal de crime (preceito penal primário) não prevê e nem exige a necessidade de dolo específico. Ademais, não há qualquer prova produzida nos autos no sentido de que tenha ocorrido a completa supressão da vontade.

Não se desconhece que o tema é polêmico. Parte da doutrina exige a presença do dolo específico e que este seria incompatível com o estado de exaltação.

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“Deve-se ter a mesma cautela quando o agente estiver descontrolado ou profundamente emocionado ou irado, pois, nessa hipótese, pode (embora não deva ser regra geral) não se configurar a vontade de depreciar a função pública o que está ínsito ao conceito de desacato, como já mencionado. No sentido de que a expressão ofensiva, usada em meio a uma discussão acalorada, não configura o crime de desacato: TJSP, AP. 253.067-3, Paulo de Faria, 5ª C., rel. Celso Limongi, 09.09.1999, v.u.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado / Guilherme de Souza Nucci. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1481).

A conduta do réu ANDERSON pode ser considerada como típica, ante a existência de comprovação do dolo de ultrajar os policiais civis que exerciam as suas regulares funções.

Ainda que o acusado estivesse completamente embriagado, o uso do álcool/droga foi espontâneo, com o que deve ser responsabilizado e não afastado o seu dolo em razão da adoção em nosso ordenamento jurídico da teoria actio libera in causa.

Registre-se que eventual uso de álcool ou droga não exime a responsabilidade do réu, porque voluntária. Recorde-se da advertência feita por Fernando Capez, ao acentuar a seguinte lição:

“A embriaguez não accidental jamais exclui a imputabilidade do agente, seja voluntária, culposa, completa ou incompleta. Isso porque ele, no momento em que ingeria a substância, era livre para decidir se devia ou não fazer. A conduta, mesmo quando praticada em estado de embriaguez completa, originou-se de um ato de livre arbítrio do sujeito, que optou por ingerir a substância quando tinha a possibilidade de não o fazer. A ação foi livre na sua causa, devendo o agente, por essa razão, ser responsabilizado”. (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, v. 1. 23. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 358).

A caracterização do crime de desacato não fica comprometida com a embriaguez

voluntária do réu, uma vez que no Direito Penal Brasileiro a embriaguez só exclui a imputabilidade quando é completa e proveniente de caso fortuito ou força maior.

Desse modo, demonstrada a procedência da imputação contra os acusados WESLEY e ANDERSON, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria das penas a serem aplicadas a eles.

WESLEY BALMANT DA SILVA

As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 são favoráveis ao réu, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal, isto é, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

O réu é reincidente (autos nº 0003631-35.2018.8.26.0320 e execução nº 0006388-33.2021.8.26.0502 - fls. 222/223). Desta forma, elevo a pena em 1/6, totalizando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Todavia, ele confessou a prática do delito e demonstrou arrependimento, de modo que opero a compensação entre a agravante e a atenuante, retornando a pena ao patamar inicial.

Não se conhece qualquer declaração de inconstitucionalidade quanto à reincidência por parte dos tribunais superiores, muito menos a necessidade de certidões cartorárias específicas para esse fim, anotando-se que a folha de antecedentes se presta para tanto.

A reincidência não implica dupla valoração negativa do mesmo fato. Nada impede o juiz de valorar negativamente na fase de fixação da pena a escolha do agente em voltar a delinquir, o que confere maior juízo de censura em relação a nova conduta delitiva praticada, não se tratando de nova punição do crime pretérito. Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF):

"AGRAVANTE - REINCIDÊNCIA - CONSTITUCIONALIDADE - Surge harmônico com a Constituição Federal o inciso I do artigo 61 do Código Penal, no que prevê, como agravante, a reincidência". (STF, RE 453000, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-194 DIVULG 02-10-2013 PUBLIC 03-10-2013).

Na terceira fase, não reconheço a existência de bis in idem, não sendo caso de incidência do redutor previsto em lei, eis que o acusado é reincidente, em conformidade com jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RÉU REINCIDENTE. ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. REGIME INICIAL. APLICAÇÃO NOS TERMOS DO DOS ARTS. 59 E 33, § 2.º, DO CÓDIGO PENAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (...) 2. Tratando-se de Paciente reincidente, não faz jus à aplicação da minorante inserta no § 4.º do art. 33 da Lei 11.343/06, nem tampouco resta caracterizado bis in idem diante da utilização da reincidência como agravante genérica e como fundamento para afastar o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, aplicável apenas ao réu primário e de bons antecedentes. Precedentes (...) 4. Ordem de Habeas Corpus denegada." (STJ, HC 231.511/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 23/08/2013).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE, REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE. APLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. ORDEM NEGADA. 1. O § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de 1º6 (um sexto) a 2/3 (dois

terços), desde que o agente preencha cumulativamente os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 2. Reconhecida pelo Colegiado Estadual a reincidência específica do paciente, não há como aplicar a minorante, porquanto não preenchidos os requisitos legais para a concessão da benesse. 3. Não há ilegalidade na utilização da reincidência como agravante genérica e para afastar o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, porquanto é possível que um mesmo instituto jurídico seja apreciado em fases distintas na dosimetria da pena, gerando efeitos diversos, conforme previsão legal específica. 4. Ordem denegada". (STJ, HC 147.271/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 30/05/2012).

"PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §4º, DA LEI N.º 11.343/2006. NÃO PREENCHIMENTO DE UM DOS SEUS REQUISITOS. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. I - Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois expressamente reconhecido na r. sentença condenatória que o paciente, por ser reincidente, não preenche os requisitos legais. II - Dentro dos limites legais, uma vez configurada a reincidência, a agravante deve ser aplicada. III - Não resta caracterizado bis in idem na utilização da reincidência como causa ensejadora da não aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, bem como agravante da pena, ante expressa previsão legal. Habeas corpus denegado". (STJ, HC 148.575/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 04/10/2010).

Ausentes quaisquer causas de aumento quanto ao acusado.

Não havendo outras causas de modificação da pena, torno-a definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, com pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Fixo cada dia-multa no mínimo legal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime inicial fechado, sobretudo pela reincidência, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, sem a aplicação do redutor previsto em lei conforme acima mencionado.

Regime diverso do fechado para quem não faz jus ao redutor legal seria de extrema benevolência, por se tratar de crime assemelhado a hediondo.

Inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por força da restrição imposta pelo art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, bem como pela suspensão condicional da pena em função da vedação do art. 44, da Lei nº 11.343/2006, assim como a reincidência.

ANDERSON RICARDO MANOEL

Artigo 33, caput, da Lei de Drogas

As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 são desfavoráveis ao réu, eis que portador de maus antecedentes criminais (fls. 45/49 - Execução nº 714.364), devendo a pena-base partir acima do mínimo legal (1/6), isto é, 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador (cf. STJ, HC 515.516/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020; EDcl no AgRg no REsp 1827892/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA

FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020 AgRg no AREsp 648.374/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016; AgRg no HC 354.093/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016; AgRg no AREsp 924.453/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 15/09/2016).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, pacificou o entendimento no Tema 150, no julgamento do RE 593818, ao fixar a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reconhecendo, portanto, o uso de condenações de definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e não atingidas pelo período depurador da reincidência, como maus antecedentes para fins de fixação da pena-base.

Na segunda fase, não reconheço qualquer agravante. Por outro lado, como o acusado confessou o delito na delegacia e a sua confissão foi utilizada para formação do convencimento do julgador, reduzo a pena ao patamar inicial de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Nos termos da Súmula 545 do STJ, "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal", de modo que reconheço a sua incidência ao caso em apreço.

Na terceira fase, não reconheço a existência de bis in idem, não sendo caso de incidência do redutor previsto em lei, eis que o acusado possui maus antecedentes, o que veda o reconhecimento do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

Ausentes quaisquer causas de aumento quanto ao acusado.

Não havendo outras causas de modificação da pena, torno-a definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, com pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Fixo cada dia-multa no mínimo legal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime inicial fechado, sobretudo pelos maus antecedentes, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, sem a aplicação do redutor previsto em lei conforme acima mencionado.

Regime diverso do fechado para quem não faz jus ao redutor legal seria de extrema benevolência, por se tratar de crime assemelhado a hediondo.

Inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por força da restrição imposta pelo art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, bem como pela suspensão condicional da pena em função da vedação do art. 44, da Lei nº 11.343/2006, assim como os maus antecedentes.

Artigo 331 do Código Penal (desacato)

As circunstâncias judiciais dos artigos 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu, eis que portador de maus antecedentes criminais (fls. 45/49 - Execução nº 714.364), devendo a pena-base partir acima do mínimo legal (1/6), isto é, 07 (sete) meses de detenção.

Na segunda fase, não há atenuantes e agravantes a serem consideradas. Não houve confissão no delito de desacato.

Fixo o regime inicial semiaberto no delito de desacato, apenado com detenção.

Reconhecida a cumulação material de crimes, vez que foram praticados mediante pluralidade de condutas e autonomia de desígnios, nos termos do artigo 69 do Código Penal, somo as penas, totalizando 05 (cinco) anos de reclusão, bem como 07 (sete) meses de detenção, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Com relação ao texto da Lei nº 12.736/2012, pondero óbice no texto completo do art.112 da LEP, que prevê, para a concessão de trânsito de um para outro regime, de vários outros aspectos, não somente o lapso temporal, como bom comportamento carcerário, por exemplo, situação que até agora não foi objeto de apuração.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o acusado WESLEY BALMANT DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, com pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 43 da Lei nº 11.343/06. Isto por considera-lo incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Por outro lado, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu ANDERSON RICARDO MANOEL, qualificado nos autos, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, com pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 43 da Lei nº 11.343/06. Isto por considera-lo incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 331 do Código Penal, na forma do artigo 69 do CP (concurso material).

Os réus WESLEY e ANDERSON poderão apelar em liberdade, uma vez que permaneceram soltos durante este processo.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual ora concedida.

Defiro a incineração da substância entorpecente apreendida com as cautelas de praxe.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido, porquanto fruto da traficância ilícita.

Como não se comprovou que a motocicleta apreendida fosse costumeiramente usada para o ilícito comércio de drogas, havendo informação de que está em nome de terceiro (cf. autos nº 0005657-98.2021.8.26.0320 – pedido de restituição em apenso), não havendo provas de que tal pessoa soubesse do envolvimento do acusado com o tráfico, tampouco que consentisse com a utilização da motocicleta para essa finalidade, defiro a restituição ao seu proprietário, observando-se, quanto à motocicleta, eventuais óbices administrativos, que deverão ser dirimidos pelas vias próprias. Oficie-se com a isenção de taxa de estadia.

Após o trânsito em julgado, os nomes dos réus deverão ser lançados no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Limeira, 24 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA